

1501338-17.2021.8.26.0642

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 "tijolos" e meio de maconha (1470g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de exame químicotoxicológico a ser oportunamente juntado). Segundo o apurado, na posse de informações sobre tráfico de drogas na moradia situada na Rua das Toninhas nº 30, policiais militares se dirigiram ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501338-17.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501338-17.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237807/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 19975927 - DEL.POL.UBATUBA, 2286/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2237807 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO MARKS RIBEIRO MACIEL MESSIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia MARCELO MARKS RIBEIRO MACIEL MESSIAS, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta de 11h, na Rua das Toninhas nº 30, Perequê- Açu, nesta cidade e comarca de Ubatuba, Marcelo Marks Ribeiro Maciel Messias, qualificado às fls. 08/9, tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 "tijolos" e meio de maconha (1470g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de exame químicotoxicológico a ser oportunamente juntado). Segundo o apurado, na posse de informações sobre

tráfico de drogas na moradia situada na Rua das Toninhas nº 30, policiais militares se dirigiram ao local e encontraram o Marcelo defronte ao imóvel, o qual correu ao avistar a viatura. Ao ser abordado ele confirmou que possuía entorpecentes em sua residência. Em buscas no local foram encontrados, dentro de um baú na sala, dois tijolos e meio de maconha (perfazendo 1470g), juntamente com uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e uma faca. Indagado informalmente, Marcelo confessou a traficância como forma de complemento de renda familiar, aduzindo ter adquirido o entorpecente na cidade de Paraty/RJ.

Interrogado, sustentou que a droga encontrada era destinada tão somente ao seu próprio consumo (fls.8/9)

Denúncia (fls. 47/50), recebida em 08 de setembro de 2021.

O acusado ofereceu Defesa prévia (fls. 144/153) onde pugnou pela absolvição sumária e, quanto ao mérito, sustentou a nulidade da prova obtida.

Em audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos exatos termos em que consta da denúncia.

A Defesa, primeiramente sustentou a nulidade do flagrante realizado pelos policiais, uma vez que houve ingresso na residência sem sua autorização e sem mandado judicial. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal. Pediu regime inicial ABERTO. Pediu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, diminuindo a pena em seu patamar máximo. Pediu a revogação da prisão preventiva do réu, com direito de recurso em liberdade. Ao final, pediu a absolvição pelo ao delito do art. 33, caput, a fixação das penas no mínimo legal.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, a qual se destina a apurar a responsabilidade penal do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

PRELIMINARMENTE

DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO

Cumpra salientar que, a despeito das alegações do acusado de que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização e sem mandado judicial, tal ingresso é válido e regular.

Vejamos.

O artigo 5º, XI, da Constituição de 1988, traz a proteção ao domicílio, tornando-o inviolável. Por domicílio, entende-se o espaço físico no qual o indivíduo goza de sua privacidade, nas suas mais variadas modalidades. Assim, o domicílio deverá ser entendido como qualquer compartimento habitado utilizada para moradia, profissão ou atividade. Por isso, escritórios, consultórios devem ser enquadrados no conceito de domicílio.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Portanto, durante o dia, é possível o ingresso em domicílio nas seguintes hipóteses: com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou mediante determinação judicial. Durante a noite, o ingresso em domicílio alheio só pode ocorrer nos seguintes casos: com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

No caso dos autos, os dois policiais militares ouvidos em juízo asseveraram ter recebido denúncia anônima de que naquele local estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, o indivíduo que estava na frente da residência, ao avistar a guarnição policial, teria se evadido do local para o interior da residência, ocasião em que foram ao seu encalço e conseguiram abordá-lo já no interior da residência.

Como acima transcrito, uma das hipóteses em que é permitido o ingresso em domicílio alheio são nas situações de flagrante delito. Ora, dos autos consta, inclusive fato

esse confessado pelo próprio acusado, que em sua residência foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 7), bem como outros petrechos comumente destinados ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão, faca, embalagens etc...

O crime de tráfico de drogas é peculiar, pois algumas de suas condutas correspondem a crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento.

Dessa forma, quem, por exemplo, guarda ou tem em depósito determinada quantidade de droga em sua residência está continuamente em flagrante delito.

Considerando a exceção trazida pelo próprio dispositivo constitucional a respeito da inviolabilidade do domicílio, conclui-se que o armazenamento de drogas em determinada residência admite a entrada de agentes policiais independentemente de autorização judicial.

No caso dos autos, haviam fundadas suspeitas de que no interior da residência do acusado estaria ocorrendo o flagrante delito. Primeiramente os policiais teriam recebido denúncia de que naquele local específico estaria sendo praticado o delito de tráfico.

Além disso, no momento em que os policiais avistaram o denunciado este teria se evadido de forma abrupta para o interior da residência, ocasião na qual conseguiu ser detido apenas no interior da residência.

Ora, o indivíduo que é flagrado na posse de substâncias entorpecentes, substâncias essas que teria confessado que eram destinados ao tráfico, e indica aos policiais a residência onde morava, bem em frente ao locais dos fatos. Tais circunstâncias permitem supor, com uma certa profundidade, de que há suspeita de que o acusado se vale da residência para raticado do ilícito.

Tais elementos justificam o ingresso dos policiais à residência do acusado sem ordem judicial, uma vez que consubstanciam fundadas razões de que naquele local estaria ocorrendo a prática do delito.

Dessa forma, observo, portanto, que a conduta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Este é, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Assim posto, resta afastada qualquer nulidade da obtenção da prova.

DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

A materialidade restou demonstrada pelo: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07), Laudo Pericial - Constatação Provisória de Entorpecente (fls. 11), bem como o Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 123/125), além de toda a prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e indubitosa.

A testemunha policial WAGNER CHARLEUX RAMOS, ouvido em juízo, narrou que: [RELATO LIVRE]

Foi radiado via COPOM, noticia de que no local dos fatos havia uma residência, onde o proprietário estaria praticando trafico de entorpecentes. Foram até o local noticiado e avistaram um veículo, o qual constou da denúncia radiada como sendo do réu. Ali viram uma pessoa em frente a residência. Quando desembarcaram, a pessoa que estava em frente a residência, correu para dentro do quintal da residência, e foram ao seu encalce. Fizeram uma abordagem nele., Não encontraram nada de ilícito. Era o proprietário da residência. Ele negou haver ilícito. Porém, ao olharem para a área da residência, visualizaram uma balança de precisão, uma faca um pouco sujo, aparentando maconha, além de um plástico filme e também um cheiro muito forte de maconha vindo de dentro da residência. Ele confessou que tinha entorpecentes na residência e que sabia que a denunciada foi feita por sua esposa. A esposa fugiu de casa e disse que iria fazer a denuncia. Ele franqueou a entrada na residência, que estava bem bagunçada. Ele mesmo mostrou onde estavam os entorpecentes. Os entorpecentes foram encontrados dentro de um móvel, come se fosse um baú, um pequeno caxote. O próprio denunciado foi quem apontou onde estava o entorpecente. A residência estava com muito cheiro de maconha. A faca estava suja de maconha. Em um primeiro momento ele negou. Mas depois ele confessou. Ele tinha dito que havia comprado há poucos dias. Ele estava saindo da casa junto com uma pessoa. Ele o viu, as características do veículo e foram abordá-lo. Ele correu para dentro do quintal da residência, eles foram atrás. Ele correu para dentro do quintal da residência. Foram atrás dele no quintal da residência e conseguiram abordá-lo.

Já a testemunha JOÃO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, em seu depoimento, relatou que: [RELATO LIVRE]

No dia receberam a denúncia via COPOM, a fins de averiguar a residência apontada. A Denúncia anônima apontava individuo fazendo tráfico no local, inclusive indicava existência de um veículo verde na garagem da residência. Chegaram ao local e avistaram um individuo em frente ao endereço denunciado e ele, ao perceber a presença da viatura, correu para o interior da residência e foram ao seu encalço, sendo abordado já no interior da residência. Encontram uma balança de precisão e uma faca suja, além de um forte odor de maconha vindo do interior da casa. O próprio acusado foi quem mostrou onde estavam os entorpecentes O entorpecente estava dentro de um móvel, como se fosse um puffe. Ele confessou informalmente a pratica do tráfico de entorpecentes. Ele estava em frente a residência. Não conhecia o rapaz e nem o local. Eles entraram na rua, procurando a residência. Eles avistaram o veículo com a característica informado. Nesse momento, ele saiu correndo para o quintal da residência. Eles correram atrás dele para o interior da residência e o abordaram.

Interrogado em juízo, o réu MARCELO MARKS RIBEIRO MACIEL MESSIAS, disse que:

não era traficante. A faca estava na cozinha. O plástico filme era para seu trabalho como tatuador. A droga era toda para seu consumo. Ele era fumante compulsivo e fazia bolos de maconha. Disse que fumava uns 10 cigarros de maconha. Cada cigarro tem 2 gramas e mis 50 gramas em cada bolo. Comprou em Trindade/Rj. Disse que somente comprou essa quantidade porque o preço estava mais barato. Ele estava na frente de casa, quando avistou a viatura ele correu para dentro de casa, os policiais foram, atrás. Foi abordado dentro da residência.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Militares, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas

circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Nesta senda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos ." (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação do acusado, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

"Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano" (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

"O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu" (Nova Teoria da Prova - 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 - pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu foi flagrado quando tinha em depósito substâncias que posteriormente foram confirmados como entorpecentes, sem autorização legal.

Eles afirmaram, com veemência, ter recebido notícias anônimas de que no endereço onde localizado o denunciado estaria sendo realizado o tráfico de entorpecentes. De fato, no local dos fatos, residência do acusado, o mesmo foi flagrado tendo em depósito a substância entorpecente devidamente apreendida (fl. 7) e posteriormente submetido à perícia (fls. 123/125), tratando-se de maconha.

- Quanto ao tráfico de entorpecentes:

Com relação ao tráfico, calha ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28 da Lei nº 11.343/06 restam consumados sempre que a conduta fática do agente se ajusta com perfeição a um dos comportamentos delineados pelos dois dispositivos legais.

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias

da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - rel. ADOLPHINO RIBEIRO - RDTJRJ 20/310).

No §2º, artigo 28, da Lei de Tóxicos, está disposto que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela grande quantidade encontrada, quantidade esta incompatível com o mero usuário.

Além disso, com o acusado foram encontrados petrechos comumente utilizados para praticado do tráfico de entorpecentes, tais quais: balança de precisão, faca e plástico filme, conforme consta do auto de exibição e apreensão de fls. 7.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das droga apreendidas, não se discute que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A quantidade de droga apreendida, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a as condições de tempo e lugar em que o acusado foi abordado, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e punível, em face de sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em observância as diretrizes do artigo 59, do

Código Penal c.c. art 42 da Lei nº 11.343/2006, note-se que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes. Todavia, merece valoração negativa a grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do apenado. Conforme se observa do laudo de constatação provisória de entorpecente (fl. 11), o acusado tinha em depósito 1k470g de maconha. Tal quantidade pode ser considerada como vultosa, mormente se pensarmos que para cada cigarro de maconha são utilizadas cerca de 2 gramas do entorpecente. As demais circunstâncias judiciais são normais à espécie de delito. Dessa forma, majoro as penas-base acima dos patamares mínimos legais, fixando-as em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho as penas no mesmo patamar.

Ainda terceira fase, a prova dos autos não é suficiente para comprovar o envolvimento do acusado com organização criminosa, nem para concluir, seguramente, que ela se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas ou outros crimes. É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas.

Além do mais, conforme entendimento das Cortes Superiores, a quantidade de entorpecente não é circunstância apta a afastar a aplicação da minorante.

Vejamos o precedente elucidativo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. APREENSÃO EM PONTO DE TRÁFICO. INDEVIDA PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. 5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 7. Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base. 8. Configura

constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 9. A apreensão de drogas e dinheiro em local conhecido como ponto de tráfico é elemento inerente ao próprio tipo penal (AgRg no HC n. 577.528/RS), não podendo ser considerada como demonstração de exercício de traficância habitual. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 664.882/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso)

No presente caso, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, à míngua de outros elementos, entendo por bem em reduzir as penas na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), diminuindo-as para 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, suficientes para a reprovação do tráfico de drogas. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares.

Tendo em vista a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado, o regime inicial de cumprimento de pena da investigada será o ABERTO em razão da quantidade da pena aplicada e atento aos critérios dos artigos 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, decidiu a C. Segunda Turma do STF: "Tráfico de entorpecentes: fixação do regime e substituição da pena. Não sendo o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. (HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028). Por isso, diante desses argumentos, entendo suficiente para a justa reprimenda a fixação de regime inicial prisional ABERTO.

Deixo de aplicar a detração para fins de fixação do regime prisional, haja vista que perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; confusão que viola os princípios de individualização penal, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

Embora ciente da nova orientação jurisprudencial, que admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que, no caso, a medida não se mostra suficiente e socialmente recomendada para o caso em tela, haja vista que, a despeito da primariedade e da ausência dos maus antecedentes, a quantidade de substância entorpecente apreendida com o custodiado lhe traz circunstâncias judiciais negativas, o que faz com que as circunstâncias judiciais não lhe sejam

inteiramente favoráveis, não sendo recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da mesma forma, entendendo por que as circunstâncias do caso, notadamente a a quantidade de entorpecente apreendido, não autorizam a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas dos réus (art. 43, da Nova Lei de Drogas).

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, passo a CONDENAR o réu MARCELO MARKS RIBEIRO MACIEL MESSIAS, qualificado nos autos às págs. 2, às penas de 1 (um) ano, 11 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO mais o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicado o redutor previsto no seu parágrafo quarto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Cumpre salientar que após estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena após condenação, a negativa do direito do sentenciado de recorrer em liberdade deve ser compatível com as condições do regime determinado. Fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Dessa forma, não há como se compatibilizar a prisão preventiva do acusado com a fixação do regime inicial diverso do fechado, mormente quando as circunstâncias do caso concreto não permitam concluir pela presença de nenhum dos fundamentos autorizadores da decretação da custódia cautelar máxima. Dessa forma, concede ao réu liberdade provisória cumulada com a medida cautelar diversa da prisão de: a) proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicação ao juízo e b) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares que impostas poderá resultar na decretação da prisão preventiva.

Não havendo impugnação específica do laudo pericial, nos termos do despacho inicial, fica autorizada a incineração das drogas apreendidas. Oficie-se.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente,

remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Ubatuba, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA